

1500110-15.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... j. 05.10.2021); e

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). Preliminares. Inépcia da denúncia. Afastada. Nulidade do Reconhecimento Pessoal. Não configurada. Reconhecimento em harmonia com o restante da prova. Preliminar afastada. Sentença Condenatória. Roubo. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

1ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500110-15.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500110-15.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2010039/2022 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 22395804 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 66/22/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2010039 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR FREITAS RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra JULIO CESAR FREITAS RIBEIRO (fls. 50/51), qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pela suposta prática do seguinte fato delituoso:

No dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 02h30min, na Rodovia Br 116, 314, Shangrila, cidade de Juquitiba e comarca de Itapecerica da Serra, o denunciado, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros indivíduos ainda não identificados, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego arma de fogo, para proveito em comum, bem como com restrição de liberdade da vítima Edivaldo

Martini, o caminhão trator marca/modelo DAF/XF FT 530, placas ELH6927, conforme boletim de ocorrência de fls. 11/13 e fls. 18/19.

A denúncia foi recebida em 11.02.2022.

Regularmente citado, o denunciado apresentou resposta à acusação, refutando o teor da denúncia e arrolando testemunhas (fls. 65/84).

Em não sendo o caso de absolvição sumária, ratificou-se o recebimento da denúncia, e designaram-se audiências instrutórias.

Nas datas aprazadas, foi ouvida a vítima, colhidos os depoimentos das testemunhas, e o réu foi interrogado. Encerrada a instrução processual, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela procedência da pretensão punitiva (termos e mídias audiovisuais das audiências).

Em memoriais, a defesa pugnou pela absolvição, por falta de prova da autoria delitiva, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em aplicação ao princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delito para furto tentado ou ameaça, com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Ainda a título eventual, postulou a fixação da pena no mínimo legal (fls. 173/181). É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais a serem sanadas e preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos boletins de ocorrência de fls. 11/13 e 18/19, no auto de exibição e apreensão do carro utilizado durante a prática criminosa (fl. 14) e nos demais elementos de informação que instruem a investigação preliminar que precedeu o oferecimento da denúncia, vertendo, ainda, da prova oral. A autoria também é certa, emergindo da prova vocal produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Em solo policial, a vítima, Edivaldo Martini, declarou que: estacionou seu caminhão no pátio do Posto Costela, no Km 314 da BR 116, para dormir, e, por volta das 02h30 min, foi surpreendido por dois indivíduos que entraram no veículo quebrando o vidro do lado direito; abordaram-no e disseram-lhe que queriam o caminhão; foi obrigado a ficar deitado na cama, sendo que os agentes questionaram sobre um rastreador; no momento em que iam sair, avistaram uma viatura da Polícia Militar, razão pela qual deram mais um tempo na cabine; nesse meio-tempo, avistou um veículo Fiat/Siena na frente do caminhão, ao tempo em que os agentes disseram que, caso fugissem, "Julio iria dançar"; após os policiais abordarem o veículo Siena, os agentes desceram do caminhão e fugiram; também desceu e pediu socorro; nada foi levado (fl. 4)

Em juízo, a vítima não logrou reconhecer formalmente o acusado como um dos autores do delito; esclareceu que o crime foi praticado por volta das 02:30h, não sendo possível visualizar os roubadores. Quanto à dinâmica delitiva, narrou que: parou o caminhão para pernoitar no km 313, no restaurante, pretendendo sair às 03:00h; por volta das 02:30, os agentes quebraram o vidro da porta do carona, pularam pela janela e renderam-no dentro da cabine; dois entraram dentro do caminhão, e o outro ficou no carro, na frente; lembra que os dois que estavam dentro mencionaram o nome "Julio"; quando a viatura chegou, pensaram em fugir, mas um deles comentou que, se fugissem, "o Julio iria dançar", dando a entender que este veio trazê-los ali para praticarem o roubo; no momento em que os roubadores iam fugir, a viatura abordou o Fiat Siena que estava na saída do posto, mas eles puxaram a cortina do caminhão e ficaram ali dentro quietos; um dos policiais focava com a lanterna em direção ao caminhão, e os agentes ficaram com medo, ocasião em que surgiu o comentário de que, caso se evadissem, "o Julio iria dançar"; ficaram mais um tempo dentro do caminhão e, quando os policiais viraram as costas, saíram correndo; neste momento, desceu e foi ao encontro da viatura, contando aos milicianos que estava sendo assaltado e que o rapaz do Fiat Siena que eles estavam abordando possivelmente seria o Julio, o qual levava os outros dois roubadores ali para fazer o assalto; os policiais já haviam pegado a habilitação do condutor do veículo e comprovado que se tratava de Julio, procedendo à sua prisão; não viu os sujeitos armados, mas eles mandaram que ficasse "de boa" para não ter troca de tiros, dando a entender que estavam armados, mas não chegou a entrever qualquer armamento; ficou com a liberdade restrita por aproximadamente vinte minutos (mídia audiovisual da segunda audiência).

Na Delegacia de Polícia, os policiais militares Daniel Jorge Costa Gomes, condutor do flagrante, e Marcio Petracone Neves, relataram que: estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, na saída do "Posto Costela", km 314 da BR 116, quando realizaram a abordagem do veículo Fiat/Siena, placas ELH-6927, conduzido pelo imputado; indagado, este trouxe várias versões sobre o motivo para estar parado ali, dentre as quais uma no sentido de que estava urinando, outra sinalizando que estava perdido, e uma terceira assinalando que estava indo encontrar com uma garota; neste momento, perceberam movimento na cabine de um caminhão; ao iluminarem o veículo, notaram que dois indivíduos correram por trás do automotor, ao tempo em que o motorista desceu pedindo socorro; a vítima afirmou ter visto um Fiat/Siena na frente de seu caminhão, assim como ouvido os comparsas do acusado falarem que, se fugissem, "o Julio iria rodar"; diante disso, conduziram o réu ao DP para as providências legais de polícia judiciária (fl. 2).

Em juízo, compromissado, Daniel reportou que: estavam em patrulhamento de rotina pela Rodovia quando, passando próximo ao "Posto do Costela", avistaram um veículo parado estacionado próximo à saída do posto, sendo que já eram mais de 2h da manhã; abordaram o veículo, e havia um cidadão no banco do motorista; por ocasião da abordagem, viram a cabine do caminhão que estava estacionado em frente abrir e fechar; iluminaram o caminhão e logo em seguida o caminhoneiro desceu, pedindo socorro, ao tempo em que viram dois indivíduos descendo; indagado, o acusado caiu em contradição, dizendo ora que estava indo buscar a namorada, ora que estava prestando serviços de Uber, ora que estava perdido; questionado, o caminhoneiro disse que acabara de ser roubado por dois indivíduos que estavam dentro do caminhão, destacando que, quando fora dormir, já havia visto o veículo Siena na frente do seu automotor; o motorista do caminhão acrescentou que, quando os sujeitos que o estavam roubando dentro do caminhão foram descer, exclamaram "ixi, o Julio dançou, vamos sair fora"; deram ciência ao Delegado e conduziram todos à Delegacia; o carro em cujo interior o acusado estava estava uns 20, 30 metros do caminhão; Julio negou que estava junto com os indivíduos do caminhão; o caminhoneiro disse que os roubadores colocaram um ferro na sua cabeça, de modo que não chegou a ver arma de fogo com eles, porém afirmaram que iriam estourar a sua cabeça; na localidade, não havia movimentação, sendo que os caminhoneiros ficam lá apenas para dormir (mídia audiovisual da primeira audiência).

Em juízo, também ouvido como testemunha, Marcio afirmou que: no dia dos fatos, Julio foi abordado próximo ao caminhão e apresentou certo nervosismo; logo após, dois indivíduos desceram do caminhão e saíram correndo; ato contínuo, o motorista do caminhão veio em direção à equipe e noticiou que estava sendo vítima de roubo, informando que, no momento em que os meliantes correram, ouviu-os dizendo "ah, o Julio rodou, o Julio rodou"; estavam em patrulhamento de rotina, e a abordagem foi feita no carro em que Julio estava; o automóvel de Julio estava cerca de 10, 15 metros do caminhão; ao abordarem Julio, não tinham notado nada de estranho na conduta de Julio, apenas após, quando os indivíduos saíram correndo do caminhão, foi despertada a suspeita; o acusado foi abordado por ser um local em que ocorrem frequentes roubos de caminhão; o réu disse que estava indo para a casa da namorada, em Cotia, rota totalmente diversa da localidade, mas não mencionou o nome da consorte; o increpado negou que estivesse atuando em comparsaria com os indivíduos que estavam no caminhão, pretextando estar perdido e que o carro em que estava era de um amigo (mídia audiovisual da primeira audiência).

Silente em solo policial (fl. 5), interrogado, em juízo, o acusado negou a prática delitiva. Alegou que: não teve nada a ver com os fatos; estava no Fiat Siena El Flex perdido, pois "errara umas entradas" e se perdera na localidade quando estava indo até a casa de uma garota; parou para urinar na pista e foi enquadrado pelo policial. Indagado por este Julgador se estava, em verdade, indo à casa da sua mulher, respondeu que não, mas, sim, que se dirigia à casa uma menina, de vez que brigara com a esposa; também respondeu que o seu celular estava sem sinal, por isso se perdera; disse que foi abordado pelos policiais assim que desceu para urinar; afirmou que o veículo Siena é do seu amigo Antonio, cujo sobrenome não conhece, que pegou emprestado para ir à casa de uma garota. Asseverou que não conhecia os outros dois que estavam dentro da cabine do caminhão. Acresceu que mora em Barueri e foi

em direção a Cotia (mídia audiovisual da segunda audiência).

Como se vê, a versão apresentada pelo acusado, afora ser totalmente dissonante, evasiva e lacônica, restou isolada no conjunto probatório, não merecendo maior credibilidade. O interrogatório, antes de ser meio de prova, compreende mecanismo de autodefesa do réu, o qual dispõe do direito a não autoincriminação – inclusive a mentir acerca dos fatos ocorridos – e ao silêncio (art. 186 do CPP). Padece, enfim, de evidente parcialidade. E a negativa tirada da autodefesa não resiste ao confronto com os demais elementos de convicção e informação amealhados no curso da persecução penal, que formam quadro convincente e bastante para lastrear o édito condenatório em relação a eles.

Muito embora a vítima não tenha reconhecido diretamente o acusado, ela foi taxativa ao ressaltar, em ambas as fases da persecução penal, que, diante da aproximação da viatura policial, os roubadores que estavam no caminhão optaram por ficar mais um tempo na cabine, dizendo que, caso fugissem “o JULIO iria dançar”. O ofendido, então, avistou o FIAT/SIENA EL FLEX parado em frente ao seu caminhão, sendo que, logo após o veículo ser abordado pelos policiais, os roubadores desceram e fugiram. Ao descer para contar aos milicianos que estava sendo assaltado e que o rapaz do Fiat Siena que eles estavam abordando possivelmente seria Julio, o qual levava os demais para fazer o assalto, os policiais já haviam pegado a habilitação do condutor do veículo e atestado que se tratava de sujeito de prenome Julio, levando à prisão em flagrante deste.

Ora, aberra da lógica a versão de que o acusado estava às 02:30h perdido justamente na cena do crime quando ia encontrar “uma garota” – considerando que ele afirmou ser casado, e dado que a localidade é totalmente divergente do destino a que ele queria chegar -, apresentando o mesmo prenome mencionado pelos roubadores que ingressaram no interior do caminhão da vítima.

Em casos como o presente, envolvendo crimes patrimoniais, há de se atribuir especial realce à palavra da vítima na elucidação dos fatos, uma vez que delitos deste jaez comumente ocorrem na clandestinidade, e não há motivos para acreditar que aquela deseje ver o acusado injusta e indevidamente condenados.

Igualmente, a jurisprudência dos tribunais superiores de há muito consolidou o entendimento de que a palavra dos agentes policiais tem eficácia probatória, desde que não se evidencie o deliberado intuito de prejudicar o réu - em virtude, por exemplo, de alguma inimizade ou perseguição pessoal. Não se patenteou a intenção dos policiais militares em incriminarem gratuitamente o acusado, e o esforço fático não se mostrou faccioso. Pelo contrário.

Mais a mais, os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados com os demais elementos dos autos, e desde que não neutralizados por álibis, têm valor probante relativo, a teor do art. 239 do CPP, e autorizam a condenação. Essa é a lição de MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA e JAYME WALMER DE FREITAS:

Para Mittermayer, indício representa um fato em relação tão precisa com outro fato que, de um, o julgador chega a outro, por conclusão natural. Então, existe a necessidade de que haja na causa dois fatos, um verificado e o outro não provado, e se prova raciocinando do conhecido para o desconhecido. Atinente ao processo criminal, o indício é o fato, circunstância acessória que se prende ao crime principal e que, por isso, concorre para se chegar à conclusão, ou de um indivíduo ter cometido o crime, ou de ter nele participado, ou de ter sido o crime consumado desta ou daquela maneira (ob. cit., p. 496).

É, portanto, uma prova indireta ou crítica, porque a representação do fato a ser provado é construída por intermédio de uma construção lógico-crítica, na acepção do crime; a indireta é aquela que prova fatos circunstanciais que rodeiam o thema probandum, mas permite que o juiz, com esteio no princípio do livre convencimento motivado, raciocine e decida sobre o mérito da infração penal. Os indícios permitem esse raciocínio.

(...)

O indício é um meio de prova, a exemplo das provas diretas, e seu valor é relativo. Uma coleção de indícios concatenados, coerentes e harmonizados com os demais elementos dos autos gera a certeza reclamada para um decreto condenatório. (Código de Processo Penal comentado, São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 379/381).

Na mesma linha:

Indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado. (MIRABETE, Julio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 10ª edição, Atlas, 2003, p. 617). Não ignoro, ainda, que os elementos informativos coligidos na senda policial não podem lastrear, por si sós, a responsabilização criminal, nos moldes do art. 155 do CPP. Isso não significa, no entanto, que o julgador não possa deles lançar mão para robustecer sua convicção quando forem reproduzidos em juízo ou corroborados por provas produzidas no curso da ação penal, na arena do contraditório. Na precisa colocação de NORBERTO AVENA:

Conforme dispõe o art. 155 do CPP, a liberdade de valoração restringe-se à prova produzida sob o contraditório judicial. Ressalte-se que o referido dispositivo não proibiu o magistrado de utilizar eventuais provas produzidas na fase extrajudicial como elementos de convicção secundários, restringindo, apenas, a possibilidade de serem estes os fundamentos exclusivos do seu convencimento. (Processo Penal – 11. ed. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo; MÉTODO, 2019, p. 449). (Negrito no original).

Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 1º, II E IV, DA LEI N. 8.137/1990, C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL, E 11 DA LEI N. 8.137/1990. INQUÉRITO POLICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. TRANCAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O inquérito policial é procedimento administrativo instaurado com a finalidade de se colherem elementos de informação acerca de autoria e materialidade de determinado crime, tão somente para o Ministério Público poder dar ou não início à ação penal. 2. Por força de norma prevista no art. 155 do CPP, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva, na qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). O juiz pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual; por isso não se verifica nenhum constrangimento ilegal a que esteja submetido o ora recorrente, ausente, ademais, qualquer prejuízo.

(...).

5. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC 47.938/CE, 6ª Turma, rel. Min.

Rogério Schietti Cruz, DJe 21.11.2017).

De resto, como bem pontuou o eminente Desembargador Marcelo Gordo, por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 1513588-34.2019.8.26.0228 pela 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, sob a sua relatoria, “apego fetichista a exigir abundância probatória para além do necessário ao convencimento do Magistrado culminaria com deixar não solucionados um sem número de delitos contra o patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe de testemunhas”.

Portanto, tendo em conta os demais elementos constantes dos autos, a questão relativa ao reconhecimento estritamente formal do acusado em juízo pela vítima não é decisiva na definição da autoria. Harmonizados os relatos extrajudiciais e judiciais, não há que se falar em insuficiência probatória. Nesse sentido:

Apelação. Crimes de roubo majorado (concurso de agentes) e corrupção de menores. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Não é o caso de reconhecimento da invalidade do reconhecimento policial. Tampouco a falta de reconhecimento judicial macula o processo. Na realidade, tendo em conta os demais elementos constantes dos autos, a questão relativa ao reconhecimento não é decisiva na definição da autoria. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do acusado pelo crime de roubo. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Ressalvada a opinião do relator, esta Câmara tem entendido que o crime de corrupção de menores é de natureza material, reclamando, para sua configuração, demonstração de que o agente, de qualquer forma, contribuiu para corromper ou facilitar a corrupção do menor, não bastando o simples concurso criminoso com o

mesmo. 3. Sanção que comporta redimensionamento. Apelo parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1503061-87.2019.8.26.0530, 14ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Laerte Marrone, j. 05.10.2021); e APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). Preliminares. Inépcia da denúncia. Afastada. Nulidade do Reconhecimento Pessoal. Não configurada. Reconhecimento em harmonia com o restante da prova. Preliminar afastada. Sentença Condenatória. Roubo. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e da policial. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas corretas. Causas de aumento devidamente constatadas. Roubo praticado em concurso de agentes mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Regime inicial fechado mantido. Recurso não provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 0009367-66.2015.8.26.0602, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Freddy Lourenço Ruiz Costa, j. 22.02.2022).

Assentadas a materialidade delitiva e a autoria delitivas, resta operar a qualificação jurídico-penal dos fatos.

Descabida a desclassificação do crime de roubo (art. 157 do CP) para o de furto (art. 155 do CP) ou de ameaça (art. 147 do CP). Diversamente do sustentado pela combativa defesa, ficou demonstrada pela oitiva da vítima a presença do elemento subjetivo especial do tipo (intenção de apoderar-se do bem da vítima, visando a ter a coisa para si). A abordagem feita pelos agentes, anunciando o assalto, mediante grave ameaça, com o fito de suprimir a possibilidade de resistência do ofendido, consubstancia-se em prenúncio de acontecimento desagradável, com força intimidativa, importante e sério, o que caracteriza roubo, crime de forma livre. Na lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

Grave ameaça ou violência a pessoa: a grave ameaça é o prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério. O termo violência, quando mencionado nos tipos penais, como regra, é traduzido como toda forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana. Lembremos, no entanto, que violência, na essência, é qualquer modo de constrangimento ou força, que pode ser física ou moral. Logo, bastaria mencionar nos tipos, quando fosse o caso, a palavra violência, para se considerar a física e a moral, que é a grave ameaça. Mas, por tradição, preferiu o legislador separá-las, citando a grave ameaça (violência moral) e a violência, esta considerada, então, a física ou real. Na jurisprudência: STF: "Configura-se o crime de roubo quando a subtração do bem é cometida mediante violência ou grave ameaça. Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto. É desnecessário que a violência física perpetrada cause dano à integridade corporal da vítima, sendo suficiente, para a caracterização do roubo, imposição de força física, material ou simples vias de fato capazes de minar a possibilidade de resistência à subtração do bem. Precedentes" (HC 107.147- MG, 1.ª T., rel. Rosa Weber, 17.04.2012, v.u.). (Código Penal comentado - 20. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 787). (Negrito no original).

Essa é a compreensão do Tribunal de Justiça de São Paulo a respeito:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade delitiva - confissão da subtração pelos réus, testemunho da vítima e dos policiais - desclassificação para furto qualificado - roubo configurado - emprego de grave ameaça - simulacro de arma - Condenação mantida - Pena criteriosamente calculada - Regime inicial semiaberto aos acusados Marco Aurélio e Luiz Otávio que se mostra adequado - Incabível o acolhimento do pleito ministerial de fixação do regime incabível com base unicamente na gravidade do crime - Regime aberto ao acusado Daniel - possibilidade - réu primário e quantum da pena - RESISTÊNCIA - configuração - possibilidade réu palavra dos policiais e da vítima de roubo, que presenciou o ocorrido -
- Recursos do Ministério Público, de Marco Aurélio e Luiz Otávio improvidos e parcialmente provido ao acusado Daniel (voto n.º 38732). (Apelação nº 0000541-07.2017.8.26.0594, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Newton Neves, j. 31.01.2019). (Negritei);

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Defesa pede, de início, o direito de recorrer em liberdade. No mérito: (i) a desclassificação para

o delito de furto; (ii) o reconhecimento da tentativa. Subsidiariamente, que: (i) seja afastada a causa de aumento do concurso de agentes; e (ii) haja a consideração da confissão espontânea, com a diminuição da reprimenda imposta. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos das vítimas coesos.

O direito de recorrer em liberdade resta prejudicado pelo presente julgamento.

Ademais, ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, de modo que a custódia deve ser mantida.

Não se há falar em desclassificação para furto. A grave ameaça restou sobejamente demonstrada, sendo perpetrada mediante simulacro de arma de fogo, conforme depreende dos coesos depoimentos prestados pela vítima.

Também não se fala em crime tentado, porquanto houve a total inversão da posse da res furtiva (teoria da amotio), ainda que por breve período de tempo, não sendo necessária a posse mansa e pacífica.

A pena não merece reparos. Fixada no mínimo legal na primeira fase. A confissão parcial não caracteriza atenuante. Ainda que se considerasse, não poderia a pena, nesta fase dosimétrica, ficar aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, de rigor o reconhecimento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, posto que as vítimas narraram com clareza que foram dois indivíduos que perpetraram o delito.

Regime fechado - Recurso não provido. (Apelação nº 0006570-03.2015.8.26.0543, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Carlos Monnerat, j. 20.10.2016). (Negritei); e

APELAÇÕES - Roubo tentado - Artigo 157, caput, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

1. RECURSO DEFENSIVO - Autoria e materialidade comprovadas - Confissão - Prova oral - Palavra da vítima - Relevância - Reconhecimento pessoal - Prova testemunhal - Condenação mantida - Desclassificação do roubo para furto - Impossibilidade - O delito foi cometido mediante grave ameaça contra a vítima - Regime semiaberto - Adequado à espécie - Substituição da carcerária por restritivas de direitos - Impossibilidade - Crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa - Suspensão condicional da pena - Impossibilidade - Quantum de pena supera o patamar estabelecido. APELO NÃO PROVIDO.

2. RECURSO MINISTERIAL - Afastamento da tentativa para condenar o acusado pela prática do delito consumado - Necessidade - O crime de roubo consuma-se quando o agente, após subtrair coisa alheia móvel, mediante o emprego de grave ameaça ou violência, passa a ter a posse da res furtiva fora da esfera de vigilância da vítima, não se exigindo, todavia, a posse mansa e pacífica do bem - Delito consumado - Pena - Dosimetria - Afastada a redução da reprimenda, efetuada na terceira fase de dosagem, face à tentativa - APELO MINISTERIAL PROVIDO. (Apelação nº 3001548-68.2013.8.26.0223, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, rel. Des. Silmar Fernandes, j. 07.10.2016). (Negritei).

Destaco que o fato de o acusado não ter ingressado no caminhão, ficando no veículo Siena para proporcionar fuga aos comparsas, não arreda o seu envolvimento no cometimento do roubo. Já se sedimentou nas Cortes Superiores a orientação de que o motorista do veículo que propicia fuga aos comparsas desenvolve ação fundamental para o êxito da empreitada criminosa, figurando como coautor. Conquanto ao ângulo da teoria restritiva objetivo-formal não se possa dizer que é coautor - já que não praticou o verbo ou núcleo do tipo penal -, é inegável que, à luz da teoria do domínio do fato, amplamente aceita pelos nossos tribunais, tal agente deve ser reputado coautor do delito. Afinal, tinha o domínio final do fato, o poder de interromper o curso dos acontecimentos, bastando que adentrasse no caminhão e impedisse a consumação do delito, ou, antes, desde que não fornecesse as informações que visavam a permitir o êxito da empreitada delitiva.

O concurso de pessoas restou configurado, incidindo a causa de aumento do art. 157, § 2º, II, do CP. O acusado agiu previamente conluiado com outros dois roubadores, sendo irrelevante que estes últimos não tenham sido identificados.

Também ficou bem delineada a majorante da restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V, do CP). Os agentes mantiveram esta refém dentro do caminhão por volta de 20 minutos, tempo juridicamente relevante para levarem a efeito o delito,

garantindo a fuga segura. No ponto, confirmam-se, por todos, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: HC n. 212613/MG - 2011/0158389-2, 5ª Turma, rel.^a Min.^a Laurita Vaz, j. 15.10.2013, DJe 25.10.2013; EDcl no REsp n. 1286810/RS - 2011/0246710-7, 5ª Turma, rel. Min. Campos Marques/Desembargador convocado do TJ/PR, j. 23.04.2013, DJe 26.04.2013; e HC n. 180586/RJ - 2010/0138451-7, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 16.02.2012, DJe 05.03.2012.

Já a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) deve ser arredada. Ressai da oitiva da vítima que ela não viu os sujeitos armados, apenas foi por eles ordenado que ficasse “de boa” para não ter troca de tiros, dando a entender que estavam armados. Como a vítima não chegou a ver armamento em poder dos agentes, sendo a palavra daquela o único elemento apto a certificar a concorrência da majorante do emprego de arma de fogo, a dúvida deve militar em prol da defesa.

Concorrendo duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, o juiz pode limitar-se a uma só majoração, prevalecendo, todavia, a majorante que mais aumenta a reprimenda (art. 68, parágrafo único, do CP). Como anota CLEBER MASSON, “cuida-se de faculdade judicial. (...) Nada impede, porém, a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena.” (Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120) – v. 1 – 15. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2021, p. 619). Fica a cargo do juiz, em sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a majoração, sem que haja um critério meramente matemático, ancorado tão somente no número de causas de aumento (Súmula nº 443 do STJ).

Tenho que um crime de roubo com uma só majorante não pode ser tratado da mesma forma que outro com mais de uma majorante. É possível que o magistrado empregue uma causa de aumento de pena para aumentar a pena, enquanto majorante, e utilize a outra como circunstância agravante ou judicial, na segunda ou na terceira fase da dosimetria, a depender de estar elencada no rol dos arts. 61 e 62 do Código Penal, ou não.

Não importa, vale ressaltar, a denominação a ser atribuída às majorantes remanescentes (aquelas não consideradas como causa especial de aumento de pena), o importante é que o critério seja este: quanto maior o número de majorantes, maior deve ser a pena aplicada. Isso não significa que, quando houver apenas uma causa especial de aumento de pena, o aumento deva ser sempre o mínimo (um terço) ou vice-versa, pois tudo depende das circunstâncias em que o fato aconteceu. Mas, nas mesmas circunstâncias, quanto maior for o número de majorantes, maior deverá ser a pena.

Esse entendimento é esposado tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (vide, por todos: AgRg no REsp 1551168/AL, rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016; e AgRg no AREsp 964.126/DF, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

Portanto a majorante referente à restrição da liberdade da vítima deverá aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, enquanto aquela do concurso de pessoas a exasperará na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, observado o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

De outro vértice, é de ser reconhecida a prática do delito na sua forma tentada (art. 14, II, do Código Penal). Delito material que é, a consumação do roubo requer a perda, mesmo que momentânea, do bem subtraído (adoção da teoria da amotio, consolidada na Súmula nº 582 do STJ). No caso vertente, não houve a perda, ainda que momentânea, da res furtiva. Embora tenham sido praticados os atos executórios, com o fito de subtrair coisa alheia móvel (caminhão da vítima), o delito não foi levado a efeito por circunstâncias alheias à vontade do agente – ação policial -, divisando-se a figura da tentativa.

Levando em consideração o iter criminis percorrido, reputo que o agente se aproximou de forma estreita da consumação do delito, chegando a se apoderar da res furtiva, de modo que a diminuição da pena deve ser no grau mínimo de um terço (art. 14, parágrafo único, do CP).

O acusado praticou, pois, a conduta descrita no art. 157, § 2º, incisos II e V,

combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Logo, ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e causas de extinção da punibilidade, a responsabilização do acusado é de rigor, ao que passo a dosar a pena aplicável a ele, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (arts. 59 e 68).

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas pelo art. 59 do Código Penal, verifico que: a culpabilidade é normal à espécie delitiva; o réu é primário (fl. 22); não há maiores informações sobre a conduta social e a personalidade do agente, não ensejando maior desvalor; os motivos são inerentes ao elemento subjetivo do tipo penal, não merecendo valoração negativa; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o delito foi praticado em concurso de pessoas, o que o torna mais grave, se comparado ao perpetrado por um único agente - tanto que a pluralidade de autores foi considerada pelo legislador como causa de aumento de pena -, de modo que exasperarei a reprimenda nesta fase no tocante àquela referente ao concurso de pessoas, conforme exposto na fundamentação; as consequências do crime são inatas ao tipo penal, no aspecto objetivo, e/ou compreendem majorantes, não comportando avaliação negativa, sob pena de bis in idem; e o comportamento das vítimas é circunstância neutra ou favorável.

À vista da circunstância judicial desfavorável, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, incide a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), porque o acusado, nascido em 30.04.2021 (fl. 22), era menor de 21 anos na data dos fatos. Não diviso, por outro lado, agravantes.

Entretanto, a fim de não desrespeitar o patamar mínimo estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal (Súmula nº 231 do STJ), atenuarei a pena no grau máximo de 1/6 (um sexto), devolvendo-a ao piso de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, concorrem as causas de aumento do § 2º, incisos II e V, do art. 157 do Código Penal, de modo que procedo à majoração de 1/3 (um terço) pela restrição à liberdade da vítima, consoante supra fundamentado, passando a dosar a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

De outro lado, há de ser reconhecida a modalidade tentada do delito (art. 14, II, do Código Penal), razão pela qual diminuo a pena no patamar mínimo legal de 1/3 (um terço) - conforme motivado acima -, tornando-a definitiva em 3 anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa.

Ausentes maiores informações sobre a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena corporal, com fulcro no art. 33, § 2º, "b", 2º § 3º do Código Penal. Embora o réu seja primário, cuida-se de roubo praticado em concurso de agentes (circunstância judicial desfavorável), mediante grave ameaça e com restrição à liberdade da vítima, circunstâncias que denotam a gravidade concreta do crime, de maneira que reputo o regime intermediário o mais adequado para atingir a função preventiva específica da pena, consistente em inibir a prática de novas empreitadas delitivas, não se cogitando, assim, de violação às Súmulas nºs 440, 718 e 719, a primeira do STJ e as duas últimas do STF (mutatis mutandis: TJSP, Apelação Criminal nº 1505924-49.2019.8.26.0228, 6ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 20.05.2021; e TJSP, Apelação Criminal nº 1502451-43.2020.8.26.0544, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 31.05.2021).

O tempo de prisão provisória não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena corporal (art. 387, § 2º, do CPP). Como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "com o advento da Lei 12.736/12, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de

prisão cautelar do acusado" (HC n. 443.419/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.06.2018, DJe 12.06.2018). Na hipótese, o tempo de prisão provisória – o réu está preso desde 12.01.2022 – não autoriza a alteração do regime penitenciário, por se estar diante de crime hediondo (art. 112, V, da LEP). Eventuais pleitos de progressão de regime e detração penal devem ser formulados perante o juízo das execuções, competente para tanto (art. 66, III, "b" e "c", da LEP), até porque ausentes notícias sobre a real situação carcerária do acusado (art. 112, § 1º, da LEP). Nessa linha:

Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo (artigo 157, § 2º, inciso II e §2ºA, inciso I, do Código Penal). Insurgência da Defesa pleiteando a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento do aumento aplicado à pena em virtude do emprego da arma de fogo e a aplicação de apenas um aumento na terceira fase da dosimetria, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, além da fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena corporal e a aplicação da detração penal. Impossibilidade da aplicação da absolvição pleiteada. Robusto conjunto probatório que impõe a manutenção da condenação do réu. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas provas dos autos. (...). Regime fechado mantido ante a gravidade do crime praticado e a reincidência em crime patrimonial ostentada pelo réu. Pedido de detração que deve ser apreciado pelo juízo das execuções. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, Apelação Criminal nº 0091137-83.2018.8.26.0050, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Osni Pereira, j. 06.05.2021). (Negritei). Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em virtude da grave ameaça à pessoa e das circunstâncias judiciais desfavoráveis (arts. 44, I, e 77, II, ambos do Código Penal).

Denego o apelo em liberdade. Da gravidade concreta do crime praticado em concurso de pessoas e mediante restrição da liberdade da vítima, emerge que, caso solto, o acusado poderá colocar em xeque a tranquilidade social, porquanto terá os mesmos estímulos para delinquir. No preciso escólio de NORBERTO AVENA:

Entende-se justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir. (...)

Neste mesmo prisma, Guilherme de Souza Nucci, aduzindo, quanto à garantia da ordem pública, que se entende pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social. (op. cit., p. 1.004).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu JULIO CESAR FREITAS RIBEIRO, já qualificado nos autos, como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 3 anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 9 (nove) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

Consoante fundamentação supra, mantenho a prisão preventiva do réu, denegando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Porém, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visando à compatibilização da segregação cautelar ao regime imposto na sentença, DETERMINO A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DO RÉU A ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO, o que faço em atenção ao entendimento do STJ, secundado pelo TJSP:

(...) 2 - Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes.

(...)” (STJ, RHC: 140941 BA 2021/0003012-8, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJ 20.04.2021, DJe 28.04.2021);

(...) 4. A imposição do regime inicial semiaberto ao paciente, por si só, não lhe confere o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Expedição de ofício recomendatório com a determinação de expedição da guia de recolhimento provisória sendo assegurado ao paciente a permanência em regime prisional compatível com aquele estabelecido em sentença. (...) (TJSP, HC: 2253601-05.2020.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 26.11.2020); e

(...) Manutenção da custódia preventiva que é compatível com a imposição do regime intermediário. Necessidade de mera adequação da situação carcerária do sentenciado ao regime ficado no édito condenatório. Ordem concedida em parte para determinar que o Juízo a quo adote, no prazo de 30 dias, as providências cabíveis para transferir o acusado ao regime intermediário, em observância à sumula vinculante nº 56 do C. STF. (TJSP, HC 2059949-86.2021.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio Coelho, j. 30.04.2021).

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, do CPP), em virtude da ausência de pedido expresso da acusação na peça inaugural, o que impediu o necessário contraditório a respeito (a esse respeito: HC 321.279/PE, 5ª Turma, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 23.06.2015).

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Intime-se a vítima do teor deste julgado (art. 201, § 2º, do CPP).

Com o trânsito em julgado desta sentença: (a) lance-se o nome do réu no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (c) oficie-se ao IIRGD para cadastro dos antecedentes; (d) expeça-se a documentação necessária para a execução das penas; e (e) remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo das multas, intimando-se, em seguida, o acusado para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (art. 50 do CP).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Itapecerica da Serra, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA